

<제9장 무효등 확인소송.제3절 무효등 확인소송의 심리>

I. 심리의 기본원칙

- 무효등 확인소송의 심리는 행정소송법 제38조 제1항에 의해 취소소송의 심리에 관한 규정(제26조)이 준용된다.

1. 직권심리주의

- 행정소송법 제26조는 법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다.라고 규정한다 무효등 확인소송에서도 이 규정이 준용되어 직권심리주의가 적용된다. 이는 행정소송이 공익성을 띠고 있으며, 처분의 위법성 판단이 공익과 관련되므로, 법원이 당사자의 주장에만 얽매이지 않고 실체적 진실을 발견할 의무를 진다는 취지이다. 다만, 직권심리주의가 적용된다고 하여 당사자의 주장 책임이나 입증 책임이 완전히 면제되는 것은 아니며, 이는 법원의 권한이자 의무를 규정한 것으로 해석된다.

2. 구술심리주의 및 공개심리주의

- 무효등 확인소송 또한 다른 항고소송과 마찬가지로 민사소송법의 규정이 준용되어 구술심리주의(변론은 구술로 진행)와 공개심리주의(심리와 판결은 공개)가 원칙으로 적용된다.

II. 주장책임과 입증책임

- 주장책임과 입증책임은 소송에서 당사자의 권리 구제 여부를 결정하는 중요한 요소이다.

1. 주장책임

- 주장책임이란 소송의 당사자가 자기에게 유리한 판결을 얻기 위해 소송 요건이나 청구 원인에 관한 사실을 주장해야 하는 책임을 말한다.

(1) 원고의 주장책임

- 원고는 처분의 위법성을 입증하기 위해 소송 요건과 청구 원인(처분의 무효 사유)에 해당하는 구체적인 사실을 주장해야 한다. 무효확인소송에서는 특히 처분등에 중대하고 명백한 하자가 있음을 구체적으로 주장해야 한다.

(2) 피고의 주장책임

- 피고인 행정청은 자신의 처분이 적법하다는 사실과 청구 원인 이외의 항변 사실을 주장해야 한다. 법원이 직권으로 심리할 수 있다고 하더라도, 당사자는 자신의 주장을 명확히 정리하여 법원에 제출할 의무가 있다.

2. 입증책임

- 입증책임이란 법관이 어떤 사실의 존재 여부를 확신할 수 없을 때, 그 사실의 존부가 불분명함으로 인해 불이익을 받게 되는 당사자가 지는 책임을 말한다.

(1) 원칙

- 행정소송법에 입증책임에 관한 특별한 규정은 없으므로, 민사소송법상의 일반 원칙에 따라 원고가 처분의 위법성을, 피고가 처분의 적법성을 입증해야 한다는 원칙이 적용된다. 즉, 소극적 사실을 주장하는 자가 아니라 적극적 사실을 주장하는 자가 그 사실에 대한 입증책임을 진다. 따라서 처분의 무효 사유(중대하고 명백한 하자)의 존재는 원고가 입증해야 하며, 처분의 적법 사유나 항변 사유는 피고가 입증해야 한다.

(2) 행정소송의 특수성

- 다만, 행정소송에서는 처분 과정에 관한 자료가 대부분 피고인 행정청에 편중되어 있으므로, 단순히 형식적인 입증책임 분배 원칙을 고수할 경우 원고에게 가혹할 수 있다. 따라서 법원은 직권심리주의를 활용하거나 입증책임을 경감하는 방향으로 운영하는 경향이 있다. 예를 들어 피고에게 관련 문서를 제출하게 하거나, 법률 요건을 충족했음을 주장하는 측에 입증책임을 부담하게 하는 등 실질적 평등을 기하려는 노력을 한다.

III. 위법성 판단의 기준

- 위법성 판단의 기준이란, 법원이 처분의 위법성 유무를 판단할 때 언제 시점을 기준으로 해당 처분의 법적합성을 판단해야 하는지의 문제이다.

1. 문제의 소재

- 취소소송에서는 처분 시를 기준으로 할 것인지, 아니면 사실심 변론종결 시를 기준으로 할 것인지가 주된 쟁점이 된다. 무효등 확인소송은 제소기간의 제한이 없어 소송이 장기간 계속될 수 있고, 처분 후에 법령이나 사실 관계의 변경이 있을 수 있으므로 기준시의 설정이 중요하다.

2. 판례의 태도

- 판례는 무효확인소송 역시 취소소송의 법리와 마찬가지로 처분의 위법성 유무는 처분 당시를 기준으로 판단해야 한다고 본다. 처분 시를 기준으로 해야 하는 이유는 다음과 같다.

(1) 법적 안정성 확보

- 행정처분은 처분 시에 이미 그 효력이 발생하거나(취소 사유의 경우), 효력이 발생하지 않았는지(무효 사유의 경우)가 확정되므로, 처분의 위법성을 후행하는 사정으로 평가하는 것은 법적 안정성을 해칠 수 있다.

(2) 항고소송의 특성

- 무효등 확인소송은 행정청의 과거의 위법한 처분 행위를 사후적으로 심사하는 항고소송의 본질을 가지므로, 처분 시에 존재했던 하자를 기준으로 판단하는 것이 타당하다. 즉, 처분 후의 법령이나 사실의 변경은 원칙적으로 고려 대상이 아니다.

IV. 결론

- 무효등 확인소송의 심리는 취소소송의 심리 원칙을 대부분 준용하나, 무효인 처분은 중대하고 명백한 하자에 중점을 둔다는 특성을 가진다. 심리는 직권심리주의와 구술심리주의를 기본 원칙으로 하며, 입증책임은 원칙적으로 위법성을 주장하는 원고에게 있으나 법원은 직권심리를 통해 실질적 공평을 기한다. 또한, 처분의 위법성 판단의 기준이 되는 시점은 소송 계속 중 발생한 사정 변경을 고려하지 않고 처분 당시로 한다.